

0008626-98.2009.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de Justiça paulista:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. Pleito objetivando a absolvição. 1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008626-98.2009.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008626-98.2009.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 027/2005 - Delegacia de Polícia de Manduri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sidney José de Melo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra SIDNEY JOSÉ DE MELO, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, supostamente, no horário e local descritos na denúncia, ajustado e mediante unidade de desígnios, por meio de grave ameaça, subtraiu, para si, uma bolsa de mão, contendo em seu interior telefone celular, documentos pessoais, carteira e outros objetos pertencentes à vítima Alceu Marques. A denúncia foi recebida, e o increpado devidamente citado, tendo apresentado resposta à acusação, refutando o teor da denúncia (fls. 267/268). Em não se entrevendo hipótese de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento.

Na data aprazada, foi colhida a prova oral, e encerrou-se a instrução processual. Em memoriais, o Ministério Público e a defesa pugnaram pela absolvição do acusado, por falta de provas da autoria delitiva (fls. 351/353 e 357/357-verso). É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64). Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso concreto, a despeito de os indícios amealhados na fase pré-processual lastrearem a materialidade do crime imputado, apontando o acusado como possível coautor, não foram coligidas, em juízo, provas suficientes para a condenação. Com efeito, a vítima Alceu Marques não foi ouvida em juízo, por ter falecido, e as testemunhas Luiz Antonio Mendes Martins e Alexandre José de Faria Lopes não prestaram depoimentos aptos a certificar, com o grau de certeza necessário à prolação do edito condenatório, a autoria irrogada ao acusado.

Luiz Antonio contou que é policial militar da reserva e que no dia dos fatos foi acionado para atender a ocorrência. Disse que pouco se recorda dos fatos.

Alexandre, Policial Civil, relatou que: estava de plantão na Delegacia de Polícia na data dos fatos, tendo sido contatado por Odair, que teria reconhecido a bolsa de Alceu em poder de Sidney; Sidney mencionou ter visto Leandro agredindo Alceu, e, tendo este ficado desacordado, pegou a bolsa para devolvê-la posteriormente; rememora-se que a vítima narrou ter sido o crime perpetrado tão somente por Leandro.

Interrogado, o acusado negou a prática do crime; alegou que: presenciou Leandro agredir Alceu; tendo este desmaiado, pegou a bolsa para devolvê-la a Alceu; após, entregou a bolsa ao dono do bar que Alceu frequentava.

Nesse cenário, os elementos de autoria delitiva são tão somente os informativos, colhidos nos autos do inquérito policial, não podendo lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Como anotam EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER:

'Elementos informativos e elementos probatórios: Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio.

A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos.

Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da

defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

A nova redação do art. 155, trazida pela Lei nº 11.690/08, inova. E, para pior, a depender da extensão de sua aplicação.

Diz o texto: “não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. O que significaria isso?

Em primeiro lugar, é de se atentar para o fato de que a expressão “exclusivamente” não constava do anteprojeto original que veio a se transformar na Lei nº 11.690/08.

A ideia inicial era afastar qualquer possibilidade de valoração de material probante produzido unicamente na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares que não pudessem ser repetidas no curso da instrução (interceptações telefônicas, perícias em que já perecido o objeto da prova etc.). Com o acréscimo (do “exclusivamente”), levanta-se, mais uma vez, a questão acerca da possibilidade de formação de convencimento judicial com base em elementos informativos produzidos na investigação.

É de se ver, então, que a inexistência de contraditório e de ampla defesa na fase de investigação preliminar, em princípio, impede a valoração judicial de tais elementos (informativos). Como regra, é claro, já que existem provas, ressalvadas inclusive na citada Lei nº 11.690/08, cuja natureza intrínseca não permite a sua reprodução em juízo. Não se pode, por exemplo, reproduzir a conversa captada em uma interceptação telefônica. Do mesmo modo, não se realiza prova pericial quando o objeto a ser periciado já não se encontra mais à disposição. E, nada obstante, tais meios de prova são aceitos aqui e, provavelmente, na maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos.

É que, em tais situações, o contraditório é diferido, ou seja, é adiado – da fase de investigação para a fase de instrução – permitindo-se que a defesa levante objeções técnicas, do ponto de vista jurídico ou tecnológico, àquele material realizado sem o controle judicial. Por certo que a qualidade das objeções é reduzida, na medida em que se cuida de questionamentos pos factum, sem o alcance das percepções imediatas, em tempo real.

Mas, diante da relevância e da gravidade dos danos causados pela infração penal – eis aqui outra das inúmeras justificativas para um Direito Penal de intervenção mínima –, o Direito se curva à necessidade de flexibilização na interpretação até mesmo de garantias constitucionais.

A expressão “exclusivamente”, portanto, não deve ser entendida como uma porta aberta para a livre valoração do material produzido na investigação, se presentes outras provas colhidas na instrução criminal. Não. Fosse assim, o convencimento judicial poderia ser construído com base essencialmente – e não exclusivamente! – em elementos informativos, bastando apenas a referência à existência de outras provas produzidas em Juízo.

Parece-nos que o tal “exclusivamente” apenas autorizaria um juízo de ponderação, de forma e principalmente de conteúdo, acerca das provas repetidas em Juízo, isto é, sobre a prova colhida na investigação e repetida em juízo'. (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência – 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. pp. 410/411). (Negritei).

Na mesma ordem de ideias, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Adotado o sistema da persuasão racional, o juiz pode formar livremente o seu convencimento, desde que fundamente a decisão (art. 155, CPP). Sob o prisma constitucional, seguindo-se o devido processo legal, as provas válidas para a condenação devem ser extraídas do processo judicial, em que há a ampla defesa e o contraditório. Algumas provas podem advir do inquérito policial, quando são periciais e feitas, à época do crime, com urgência (ex.: laudo de local). Em nossa visão, provas que podem ser refeitas em juízo (como a testemunhal), quando realizadas na fase extrajudicial, são inúteis para fundamentar a condenação do réu. (Processo penal e execução penal, 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 82). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação de que a condenação apenas pode ser arrimada em elementos informativos coligidos no inquérito policial quando

estes forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, sob a lente do contraditório:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido." (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Logo, em atenção do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova de ter concorrido para a infração penal (art. 386, V, do CPP), é medida de rigor.

Em abono ao motivado, colaciono aresto do Tribunal de Justiça paulista:

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso da defesa. Pleito

objetivando a absolvição. 1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos.

Acusado reconhecido, exclusivamente, por meio de fotografias. Ausência de descrição dos traços fisionômicos da pessoa a ser reconhecida. Descumprimento das formalidades previstas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Acusado que não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado em poder dos objetos subtraídos. 2. Insuficiência para decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. 3. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 1500577-43.2019.8.26.0484, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 11.11.2021).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado SIDNEY JOSÉ DE MELO, qualificado nos autos, da imputação que lhes foi feita, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários em favor do(a) nobre patrono(a) nomeado(a), no valor máximo previsto na tabela vigente.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e às comunicações necessárias.

Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

P. I. C.

Piraju, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA